

1501977-25.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... que fazia abastecimento de pontos de tráfico ("gerente"). Havia também anotações de tráfico e um aparelho celular contendo conversas com negociações sobre o tráfico. Não conhecia o réu anteriormente, só o tinha visto durante as "campanas". Não se lembra se foi apreendido dinheiro.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Luciano. Acrescentou que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1501977-25.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501977-25.2022.8.26.0537 Controle nº 1496/2022

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE XAVIER BARRETO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

FELIPE XAVIER BARRETO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, e no art. 12, "caput" da Lei n.º 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, porque no dia 21 de setembro de 2022, na Rua Gema, n.º 299, Bairro Campanário, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, cocaína, "crack" e maconha, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda da denúncia, que nas mesmas condições de tempo e local acima informadas, possuía e mantinha sob sua guarda a arma de fogo de uso permitido, consistente na pistola da marca Sig Sauer, calibre 9 mm, numeração EAK111389, municiada com 12 (doze) cartuchos íntegros, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva por decisão de juíza de

plantão (fls. 38/41).

Recebida a denúncia em 28.11.22 (fls. 155/156), o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 124/125). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arrolada pelas partes. O réu foi interrogado no final, sendo seguido o rito ordinário (fls. 155). Após a fase do art. 402 do CPP, a Dra. Promotora de Justiça requereu a procedência da ação, reconhecendo-se o concurso material, com aumento da pena pela quantidade de drogas e por ser duplamente reincidente (fls. 25), fixação de regime fechado, vedado o direito de recorrer em liberdade e perdimento do dinheiro apreendido.

O defensor do acusado requereu a absolvição ou em caso de eventual condenação a fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento da confissão espontânea (que recebeu a bolsa), redução do art. 33, §4.º, detração penal, substituição por pena restritiva de direitos e direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 16), o acusado permaneceu calado.

Em juízo, afirmou que sempre foi trabalhador, tinha carteira assinada, mas com a pandemia ficou desempregado. Narrou que recebeu a proposta para guardar uma bolsa por 4 ou 5 dias, ia receber R\$300,00 e aceitou por estar desempregado e ter que pagar pensão. Não sabia o que tinha na bolsa. A arma não era sua, provavelmente estava nessa bolsa. Narrou que trabalhava como mecânico de automóveis. Tem apenas um Iphone, mas não realizava conversas sobre tráfico. Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 10/11), relataram que diligenciaram até o local dos fatos em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido no Inquérito Policial 2255687-65.2022.030122, em trâmite na 2.ª Vara Criminal local. Narraram que no local solicitaram a abertura do portão principal por um vizinho de habitação do mesmo quintal e ingressaram, quando foram informados de que se tratava, na verdade, de habitação coletiva, e que o "alvo" do mandado residiria na edificação de número 3. Disseram que ingressaram pela edificação de número 3, avistaram o réu, enquanto este se arrumava para sair, e o abordaram. Afirmaram que logo que ingressaram no local sentiram forte odor de drogas. Falaram que nos fundos do imóvel encontraram uma mulher identificada como Emely Souza da Silva, a qual chamaram para acompanhar a revista e deslocar-se até o acesso inicial da casa. Informaram que localizaram na residência, dentro de um sofá, grande quantidade de drogas, divididas em porções individualizadas, e anotações diversas de movimentações do tráfico de drogas, e que, posteriormente, sobre um armário no quarto, encontraram outra grande quantidade de entorpecentes individualizados para o comércio. Informaram que no interior de uma gaveta no quarto da casa encontraram uma pistola Sig Sauer de calibre 9mm, municada e com um carregador.

Lucas (policial), em juízo, disse que foram cumprir um mandado de busca da 2.ª Vara Criminal de Diadema por organização criminosa, referente ao réu Felipe, vulgo "Tropa". Foram até o local e um morador falou que era uma habitação coletiva, o que não tinha conhecimento, permitiu a entrada e indicou a residência do réu, entraram na casa dele e na cozinha se sentia forte cheiro de drogas. Durante a busca embaixo do sofá localizaram drogas. No quarto em cima do guarda-roupa havia mais drogas. A pistola e munições no carregador foram apreendidas dentro do guarda-roupa. O réu falou que comprou a arma para defesa pessoal e confessou que fazia abastecimento de pontos de tráfico ("gerente"). Havia também anotações de tráfico e um aparelho celular contendo conversas com negociações sobre o tráfico. Não conhecia o réu anteriormente, só o tinha visto durante as "campanas". Não se lembra se foi apreendido dinheiro.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Luciano. Acrescentou que arrombaram a residência, porque o réu não abriu. Na gaveta do criado-mudo foi ele que achou a pistola e munições. A notícia era que o réu era integrante de facção criminosa e distribuição de drogas em várias cidades. Havia sacolas já com 100 porções de cada droga, prontas para distribuição. O réu depois de achadas as drogas e armas nada falou. Tinha balança de precisão, embalagens e anotações do tráfico.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto

probatório.

"PROVA - Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º

1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade de drogas apreendidas (fls. 08 - 539 pedras de "crack", 5923 invólucros de cocaína e 5230 porções de maconha), aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em invólucros, bem como os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade e variedade se não fosse traficante.

Irrelevante que não tenham sido presenciados atos de mercancia, posto que denunciado pelas condutas de guardar e ter em depósito.

Embora o réu em juízo tenha informado que recebeu uma bolsa, informou que não sabia o conteúdo e que a arma não lhe pertencia e devia estar no interior da mesma. Logo, negou a prática dos crimes. A negativa judicial do réu está isolada, posto que alegou, mas nada provou como lhe incumbia nos termos do art. 156 do CPP e sua versão foi desmentida pelos depoimentos uníssonos dos policiais nas duas fases no sentido de que havia drogas embaixo do sofá e em cima do guarda-roupa, que estavam separadas em sacolas contendo 100 porções de cada, prontas para distribuição e não em bolsa e a arma separada das mesmas.

Apesar das ponderações da defesa em razão da grande quantidade de ocorrências que atendem, nem sempre é possível os policiais se recordarem de todos os detalhes. Porém, foram uníssonos no sentido de que as drogas e arma foram apreendidas na residência do réu.

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Desta forma, impõe-se a condenação do acusado pelo tráfico, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 21/23) e laudo definitivo (fls. 101/103).

Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo, restou demonstrado que arma e as munições foram apreendidas na residência do réu, que negou a propriedade da pistola.

A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07) e pelos laudos periciais da munição (fls. 99/100) e arma (fls. 131/133), o qual concluiu que se trata de pistola semi-automática da marca Sig Sauer calibre 9mm, com numeração de série EAK111389 e apta para disparos, pelo que é caso de condenação.

Trata-se de concurso material, porque os crimes foram praticados mediante duas ações distintas.

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é reincidente (fls. 25 - proc. 8327-32.2017 - pena julgada extinta em 21.03.22).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o tráfico, em razão da quantidade média de drogas (fls. 08 - 539 pedras de "crack", pesando aproximadamente 135g, 5923 invólucros de cocaína, com peso aproximado de 4,5 kg, e 5230 porções de maconha, pesando cerca de 5,2 kg), já que pequena quantidade em Diadema é inferior a 100 porções, em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, à razão mínima por inexistirem elementos quanto à real situação

econômica do acusado.

Aumento a pena de 1/6 pela reincidência.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, pois conforme prevê o art. 33, § 2.º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não reincidente". As circunstâncias não são favoráveis, pois é reincidente (fls. 25 - proc. 8327-32.2017 - pena julgada extinta em 21.03.22), o que denota personalidade voltada para a prática de crimes, uma vez que sequer provou possuir ocupação lícita, o que demonstra que o tráfico é seu meio de vida e, ainda, houve aumento da pena pela quantidade de drogas. Trata-se de crime de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade.

Inviável a conversão em restritiva de direitos ou "sursis", diante do montante da pena.

Inaplicável o disposto no art. 387, § 2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja, "Lex specialis derogat generali" (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenche o lapso temporal para tanto (preso em 21.09.22, pelo que ainda que considerado 2/5 só ocorreria em 26.12.25).

Por outro lado, "ad argumentandum", ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante da reincidência (circunstância judicial agravante) e extinção da pena há pouco tempo, não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tendo em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1 ano de detenção e 10 dias-multa. Aumento a pena de 1/6 pela reincidência.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, uma vez que o réu é reincidente e a pena é de detenção. Não é caso de fixar o regime aberto, posto que as circunstâncias judiciais não são favoráveis, pois é reincidente por desacato (fls. 25 - proc. 8327-32.2017 - pena julgada extinta em 21.03.22) e a condenação também é por tráfico de drogas, o que denota personalidade voltada para crimes. Quanto ao dia-multa será à razão mínima em face de sua situação econômica.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO FELIPE XAVIER BARRETO DOS SANTOS à pena de 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME FECHADO e 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, e à pena de 1 (UM) ANO e 2 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO, INICIALMENTE NO REGIME SEMIABERTO, e 11 (ONZE) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 12, "caput" da Lei n.º 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

Tendo em vista que o réu foi preso em flagrante por crime equiparado aos hediondos previsto na Lei n.º 8072/90, que o M.P não concordou com o recurso em liberdade, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, sendo crime de extrema gravidade, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes de gravidade e para assegurar a aplicação da lei penal, posto que não há nada que o vincule ao distrito da culpa (não comprovou ocupação lícita nem residência fixa) e é incabível qualquer benefício, recomende-se na prisão em que se encontra.

Como efeito da condenação, sendo o acusado condenado por crime de posse irregular de arma de fogo, fica confiscada a arma apreendida, nos termos do art. 91, inc. II, "a", do Código Penal e art. 25 do Estatuto do Desarmamento, providencie-se o

necessário.

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 07 e 54/55) conforme prova produzida é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Custas "ex lege" (Lei n.º 11.608/03).

Não há provas de que a motocicleta marca/modelo Honda/PCX 150 DLX ABS de placas FOI1G29, apreendida (fls. 08), era utilizada ou proveito do tráfico e pertence a terceiro. Assim, oficie-se, desde já, informando que devem ser tomadas as providências necessárias para eventual liberação ao seu legítimo proprietário ou, não havendo interesse por parte deste, que seja levado a leilão público, nos termos da Lei Federal 6575/78 e art. 328 do C.T.B.

Quanto aos 2 (dois) aparelhos de telefone celular apreendidos (fls. 07 - 1 telefone celular marca LG e 1 telefone celular tipo Iphone 11, marca Apple), não há provas nos autos de que eram utilizados ou são proveito do tráfico, pelo que oficie-se desde já informando que não interessam mais ao feito e que decorrido o prazo do art. 122 do CPP pode ser dado o destino pertinente.

Em relação à balança de precisão apreendida (fls. 07), já periciada (fls. 129/130), ao caderno e folhas de caderno com anotações manuscritas, apreendidos (fls. 07), tendo em vista que não possuem valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessam mais aos autos podendo ser eliminados.

Observe que os cartuchos foram utilizados em teste balístico, conforme laudo pericial (fls. 100), pelo que não há providências a serem determinadas.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 43), providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, § 4.º, da Lei n.º 11343/06) e efetue-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 07 de dezembro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA